

1501363-22.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501363-22.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501363-22.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149586/2022 - 03º D.P. AMERICANA, 25330492 - 03º D.P.

AMERICANA, 2149586 - 03º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CRISTIANO DE SOUZA PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LEONARDO RODRIGUES ALVES DA SILVA e LEONARDO CRISTIANO DE SOUZA PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inc. II, combinado com o artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, porque na data e locais descritos na denúncia, previamente conluiados e com unidade de propósito, mediante grave ameaça e violência, exercida com simulação de arma de fogo, subtraíram para o proveito comum, coisas alheias móveis, ou seja, R\$90,00 do estabelecimento comercial de propriedade de F.M.A.M.; e R\$50,25 de um posto de abastecimento de combustíveis (Auto Posto Nova Americana).

A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (fls. 127/129). E o aditamento de

fls. 207, foi recebido as fls. 218.

Os réus foram citados, apresentando defesa (fls. 154/155 e fls. 164/166).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas, e os réus foram interrogados (fls. 254/255, fls. 275/276 e fls. 281/282).

Em seus memoriais, em audiência, o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora do réu Leonardo Rodrigues (fls. 284/288) requereu aplicação da atenuante da confissão, e o reconhecimento do delito na forma tentada, com fixação de pena mínima e regime mais brando.

E, ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu Leonardo Cristiano (fls. 289/295) requereu a absolvição por falta de provas ou, alternativamente, a desclassificação.

É, em síntese, o relatório.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1º do mesmo artigo.

Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na seqüência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

" ... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato - seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

A materialidade do delito de roubo se encontra comprovada pelos autos de fls.

01/04, 05/11, 25/26, 39, 58 e 114.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Em poder dos acusados foram encontrados os bens subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor

- validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

Roubo - Objetos subtraídos encontrados em poder do agente - Ônus de demonstrar a legitimidade da posse transferido a defesa - Inteligência do art. 156 do CPP. 131 - Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. RJDTACRIM VOL.6 PÁG. 140 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-NOGUEIRA FILHO.

Ouvido em juízo, o réu Leonardo Cristiano negou a pratica dos delitos. Alegou que apenas pegou uma carona com Leonardo Rodrigues, para ir a casa da namorada. Confirmou que pararam no posto de combustível, e que ficou esperando próximo da moto.

Ouvido em juízo, o réu Leonardo Rodrigues confirmou parcialmente a pratica dos delitos. Alegou que estava sem dinheiro e queria comprar drogas, razão pela qual realizou os assaltos, sendo que Leonardo Cristiano não tinha conhecimento dos fatos.

Preliminarmente, a atenuante da confissão espontânea, relativo a Leonardo Rodrigues, prevista no artigo 65, III, letra "d" do Código Penal não pode ser aplicada no caso em tela, posto que o réu proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade), na tentativa de excluir o comparsa.

(...) o agente que confessa a autoria, quando já desenvolvidas todas as diligências e existindo fortes indícios, ao final confirmados, não faz jus à atenuante. Para a incidência desta, é necessária a admissão da autoria, quando esta ainda não era conhecida (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - Na hipótese, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta. IV - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 432.165/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)

Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo – Ação delitiva captada pela câmera de segurança – Admissão do réu quanto ao furto – Negativa a respeito do rompimento de obstáculo – Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica – Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio – Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade – Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora – Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial – Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Ainda, a versão pueril do réu Leonardo Cristiano em juízo de que não praticou o roubo qualificado, e não tinha conhecimento das ações do comparsa, restou isolada no conjunto probatório. Até porque, não provada. É notório que no caso de invocação de alibi, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte que alegou demonstra-lo. Suas ações, conforme relatadas pela testemunha Alan, comprovam que tinham conhecimento das ações do corréu Leonardo Rodrigues, e nada fez para impedir ou ausentar-se, compactuando, então, para os atos.

Em audiência, as testemunhas/vítimas, relataram o ocorrido.

José, representante do Posto de Combustível, apenas confirmou que o estabelecimento comercial foi assaltado no referido dia.

Fabia informou que é proprietária do trailer de lanches, sendo que não estava no local, e foi comunicada acerca do assalto. Disse que dirigiu-se ao estabelecimento, onde encontrou Alan, o qual estava bem nervoso. Acredita que foi subtraído cerca de cem reais. Informou que acompanhou Alan na Delegacia, quando este reconheceu os réus. Por fim, recuperou o dinheiro.

E, Alan declarou que estava fechando o trailer, quando apareceram duas pessoas de moto, o renderam e colocaram dentro do trailer, subtraindo os valores do caixa. Confirmou que o réu mostrou a arma na cintura. Informou que foi rendido por um deles, enquanto o outro permaneceu perto da moto. Relativo ao que permaneceu na moto, confirma que ele ficava dizendo "ô meu Deus", acreditando que por medo. Por fim, reconheceu os réus como os autores do delito.

Não há nos autos prova de que as vítimas/testemunhas conheciam os réus anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente'

(JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320).

No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354. (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)" (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são harmônicas, coesas e aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. III - (...). V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1144500, 20171010058690APR - 0005765-57.2017.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 157/173)

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação" (TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

PROVA - Crimes contra o patrimônio - Palavra da vítima - Valor:146 (a) - Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente. RJDTACRIM VOLUME 21 JANEIRO/MARÇO94 PÁG.:267 RELATOR:- WALTER SWENSSON.

Ainda, os guardas municipais narraram que receberam a informação acerca de um roubo em andamento, em um posto de gasolina, por dois indivíduos armados, sendo que o vigilante do local estaria os seguindo. Efetuaram patrulhamento pela região, acabando por visualizar os réus, os quais estavam em uma moto preta, com os faróis desligados, sendo que efetuaram o acompanhamento do veículo, momento em que verificaram o motorista dispensado algo, e, próximo ao local, acabaram por abordar os réus. Retornaram, então, ao local e verificaram que o objeto dispensado era um simulacro de arma de fogo. Em revista pessoal, com o motorista foi encontrada a quantia em dinheiro. Indagados, o motorista confirmou a prática do delito. Em contato com a vítima, do Quiosque, esse narrou acerca do assalto, com exibição da arma.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho.

Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade.

63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTCRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

O conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que os réus, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, realizada com simulacro de aram de fogo, subtraiu os pertences das vítimas.

Em que pese a defesa apresentada, não é possível a absolvição ou a desclassificação do delito, considerando a ameaça efetuada pelos réus, em concurso, inclusive com utilização de arma simulacro de fogo, ao proceder a subtração dos bens, restando configurado o roubo qualificado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA EM CONCURSO FORMAL. Condenação mantida. Réus confessos. Palavras do ofendido e de testemunha presencial. Desclassificação para furto afastada. Grave ameaça comprovada pela simulação do porte de arma. Crime consumado. Inversão da posse. STJ, Súmula nº 582. Penas mantidas. Maus antecedentes comprovados. Concurso formal caracterizado. Regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500056-43.2018.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 02/09/2019)

Ainda, comprovada a ameaça, e obtenção do bem, ainda que por curto período de tempo, não há que se falar em tentativa, restando configurado o delito consumado. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - Tema 916 - REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015.)

Por fim, no presente caso, os delitos ocorreram em um pequeno lapso de tempo, e foram praticados pelos mesmos comparsas, com unidade de desígnios. Destarte, deve ser considerada a continuidade delitiva, com o acréscimo previsto no artigo 71 do Código Penal. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

Apelação criminal. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Apelo Defensivo buscando absolvição, por falta de provas, ou a fixação de regime prisional menos gravoso - Materialidade e autoria comprovadas réu que foi reconhecido por ambas as vítimas réu e comparsa que cometerem o primeiro roubo, com simulação de uso de arma de fogo, subtraindo o celular do ofendido, e se evadiram. Na sequência, com mesmo 'modus operandi', réu e comparsa abordaram a segunda vítima no veículo, no interior do qual havia duas crianças, e anunciaram o carro. Vítima que implorou para retirar as crianças, e o comparsa do réu se evadiu com tal veículo, ainda com uma das portas abertas,

deixando o réu para trás. Populares que ouviram os gritos e lograram deter o réu até a chegada da Guarda Municipal. Delitos de roubo majorados perfeitamente delineados Continuidade delitiva mantida, diante das circunstâncias de tempo, praticados em locais próximos e com mesmo 'modus operandi' - Dosimetria Penas-base fixadas no mínimo legal, sem recurso Ministerial Sem alterações na segunda fase Na terceira fase, exasperação decorrente do concurso de agentes, e em razão da continuidade delitiva - Regime inicial fechado bem justificado Correção de erro material no dispositivo da sentença quanto à capitulação referente à continuidade delitiva (art. 71, do CP) - Recurso improvido. (Apelação nº 0004227-49.2015.8.26.0635, da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora: ELY AMIOKA, Data: 09/11/2017)

CRIME CONTINUADO - Dois delitos de roubo, um simples e consumado, e outro circunstanciado e tentado, praticados na mesma Cidade, no mesmo dia, com diferença de poucas horas - Reconhecimento - Possibilidade: 25 - É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo, um simples e consumado, e outro circunstanciado e tentado, praticados na mesma Cidade, no mesmo dia, com diferença de poucas horas. (Apelação nº 1.098.723/0, Julgado em 28/05/1.998, 16ª Câmara, Relator: Mesquita de Paula, RJTACRIM 39/99)

Assim sendo, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, para o delito de roubo (artigo 157, do Código Penal), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, para cada réu.

Na segunda fase, é impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante (art. 65, do CP), tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ainda, por força do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento, ensejando o roubo qualificado, acresço as penas em 1/3 (um terço), perfazendo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, ante a ocorrência de crime continuado (art. 71, do CP), e considerando a quantidade de comprovadas participações de ações (duas vítimas), aumento a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena.

Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III, do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça

embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Assim, em que pese a primariedade, ante as circunstâncias e conseqüências do crime, o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto.

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples tentado – Absolvição - Pleito ministerial requerendo condenação – Prova robusta para admitir a condenação do réu – Início da execução do crime devidamente caracterizada - Regime inicial semiaberto devido - Recurso ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500535-68.2019.8.26.0621; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Ainda, não pode apelarão em liberdade, porquanto a gravidade do crime cometida, e o modus operandi devem influenciar na concessão da liberdade para recorrer, e em se tratando de roubo praticado mediante grave ameaça e violência a pessoa, salvo prova excepcional em contrário, a regra é a prisão provisória do réu.

Assim é o entendimento de jurisprudência, conforme o V. Acórdão que segue, brilhantemente relatado pelo eminente Magistrado Haroldo Pinto da Luz Sobrinho: “O conceito amplo de bons antecedentes, como requisito da liberdade para apelar, compreende, além dos episódios da vida pretérita do réu, as circunstâncias em que praticou o delito tratado na sentença cujo reexame pretende em grau de apelação” (HC - 218.978/1 - TACRIM_SP - 2ª Câmara - Rel. Haroldo Luz - RJDTCRIM 13/196)

E, ainda:

Habeas Corpus – Condenação por roubo majorado – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2218120-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juiz sentenciante, conforme o art. 387, § 1º, do CPP, ao concluir pela necessidade da decretação da custódia cautelar ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do delito - roubo praticado com arma de fogo e concurso de agentes, em um restaurante - e pelas condições pessoais desfavoráveis do réu, decidiu conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior. Ficou consignado, ainda, que o réu possui condenações penais anteriores por crimes patrimoniais, o que denota sua reiteração delitiva. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 497.109/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ademais, os réus encontram-se presos por força de prisão preventiva, e segundo a

melhor doutrina, e jurisprudência majoritária, o dispositivo é inaplicável no caso de réu preso provisoriamente.

Segundo o ilustre penalista Damásio Evangelista de Jesus:

"Segundo o entendimento pacífico do STF, essa disposição é inaplicável a réu preso em razão de flagrante ou preventiva, uma vez que e/a visa apenas abrandar o princípio da necessidade de e/e recolher-se à prisão para apelar (RHC 54.430, DJU 26.11.76, p. 10203). Assim, réu que por ocasião de sentença condenatória se encontrava preso em razão de flagrante ou preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459, RHC 56.953, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Sobre o assunto, decidiu o TJSP que "Lei n. 5.941, de 1973, é de interpretação restrita. Não nulificou a prisão em flagrante delito, cuja permanência no sistema processual vigente, vai até a sentença. Se esta for absolutória, o réu será posto em liberdade. Se for condenatória, aquela permanência se prolonga, porque um dos seus efeitos (art. 393, I) é ser o condenado conservado na prisão. Se for de pronúncia, só então o magistrado deverá reexaminar a custódia provisória, para revogá-la caso satisfaça o agente os requisitos legais", (RT- 500/318). No mesmo sentido: RT 531/295 e RTJ 88/69; RHC 57.947, DJU 13.6.80, p. 4461, e RHC 58.053, DJU 12.8.80, p. 5786. E, se a acusação apela visando à agravação da reprimenda, o réu permanece detido, ainda que já tenha cumprido o quantum da pena imposta na sentença condenatória (Código de Processo Penal Anotado - Direito Informatizado Saraiva - 1ª Edição em CD-ROM - 1995).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"É que o paciente respondeu o processo preso cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevivendo sentença condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os atributos elencados pelo ilustre impetrante. Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. 2. Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As condições pessoais favoráveis não são requisitos bastantes para a concessão de liberdade provisória, e, ademais, no caso dos autos, o paciente não logrou demonstrar ocupação lícita e possuir residência no distrito da culpa. 4. Habeas corpus denegado." (HC nº 207.906/RJ, Quinta Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.02.2012).

E, no caso sub judice persistem os requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois os delitos apurados roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade". (AC 2018.0000350330, Habeas Corpus nº 2062136-72.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. França Carvalho, 10 de maio de 2018.)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus LEONARDO RODRIGUES ALVES DA SILVA e LEONARDO CRISTIANO DE SOUZA PEREIRA às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no piso, cada um, como incursos, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inc. II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Por fim, considerando a concessão da gratuidade da justiça (fls. 267), presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-os das custas.

P. I. C.

Americana, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA